

propriadamente dichos, otorgados en el foro o plaza pública ante quienes desempeñaban funciones análogas a la de los actuales notarios – *tabelliones*-, que hacían fe bajo la condición de que fueran confirmados por ellos bajo juramento prestado *apud* acta ante el magistrado.

- 3) Los documentos privados –*cautiones*, *chirographa*, etc.-, otorgados directamente por los particulares, generalmente en presencia de testigos, si llegaba al número de tres el instrumento se convertía en cuasi público, con efectos similares al referido en el punto dos.
- 4) Otros documentos podían servir como prueba, pero había que demostrar su autenticidad a través del juramento prestado por quienes lo llevaban a cabo o testigos, también se demostraba su autenticidad por medio de:
El cotejo de la escritura –*manus collatio*, *comparatiolitterarum*- practicado por peritos en la materia.
- 5) También estaban los *gramatici* o agrimensores, que dictaminan sobre cuestiones vinculadas con la propiedad de bienes inmuebles, su división y fijación de límites, etc.
- 6) Los médicos y las *obstetrices*, cuando se trata de acreditar, por ejemplo, la existencia de un embarazo, etc.
- 7) Pueden igualmente utilizarse la *confessio* de alguna de las partes o de ambas sobre hechos o circunstancias controvertidas y el juramento supletorio como complemento de los demás medios de prueba e incluso el decisorio cuando de su resultado se haga depender la sentencia.

Las Presunciones

Que no fueron conocidas con éste nombre por los romanos, ya que fueron una creación medieval, pero sí las pusieron en práctica: estaban las presunciones *iuris tantum*: eran las que admitían prueba en contrario, en cambio las *iures et de iure* no admitían prueba en contrario. Entre las presunciones que encontramos tenemos:

- a) La teoría de la *conmorencia*: en caso de que en un mismo accidente o infortunio perezcan dos o más personas pertenecientes a la misma familia había que “presumir” como había sido el orden de las muertes a los efectos de que ello tuviera repercusiones jurídicas posteriores como era la realización de la sucesión ab intestato. Se determinó que si los que habían perecido eran padre e hijo, en caso de que el *filius* fuera impúber moría primero éste por ofrecer menor resistencia a la muerte ello basado en las características propias de su estructura orgánica; en cambio si moría el *filius* era púber moría primero el *pater* debido a que a partir de la adolescencia había mayor resistencia del mismo a la muerte. Admitía prueba en contrario.
- b) Otro caso era el de presunción de paternidad: cuando se daban situaciones extraordinarias como era la situación de aquéllos ciudadanos de ir a las guerras o morir dejando a su mujer embarazada, a los efectos de determinar la paternidad dentro de las justas nupcias, había un plazo de 180 días, si el *filius* nacía dentro de ese lapso como mínimo desde la celebración del matrimonio no había dudas acerca de la paternidad del *pater*, el nacimiento antes de ese lapso ofrecía dudas acerca de ésta.

Estas cuestiones de asignarle un valor predeterminado a la prueba y lo avanzados que estaban los romanos en aspectos procesales y probatorios propiamente dichos como la denominada en la actualidad prueba tasada, y los medios de prueba, que, con algunas variantes propias de la evolución de los sistemas procesales se siguen realizando en la actualidad como las declaraciones testimoniales, los peritajes

caligráficos, la clasificación de instrumenta en públicos o privados, los médicos y los agrimensores.

La Sentencia

Se trata de la conclusión a la que arriba el juez en base a la actuación procesal de las partes, la producción de la prueba y los alegatos en defensa de los intereses de cada una de ellas. Es el final del proceso judicial civil que deberá resolver una cuestión conflictiva desde el punto de vista de hecho y de derecho.

Si bien su función implicaba el ejercicio de una carga pública debía fallar conforme a derecho, pero ante alguna situación que le impidiera expedirse por la duda deberá remitir las actuaciones a los efectos de que falle ante el Emperador que tenía competencia para ello sobre todo en tiempos del bajo imperio.

El Emperador actuaba por medio de funcionarios en los que delegaba la función judicial denominados *libelli refutatorie* trabajaban sobre un resumen de los alegatos y la prueba producida, escritos de las partes y actas, luego se dictaba un rescripto existiendo imposibilidad de recurrir.

Como en el derecho actual se diferenciaban las sentencias que cerraban definitivamente el proceso de aquellas denominadas sentencias interlocutorias que, son aquellas cuestiones que deben resolverse dentro del proceso general su resolución estaba a cargo de los *adse-sores*, sobre cuyo cargo y funciones nos informan el Digesto (Lib. I, tít. XXII) y el Código (Lib. I, tít. LI) justinianeos y a que se refiere una Constitución recogida en el Código Teodosiano (I, 35).

La sentencia se hacía por escrito, salvo excepciones se leía por los *illustres* en sede judicial en presencia de las partes (independientemente de que éstas asistan o no después de ser citadas), el contenido de la sentencia era inamovible en el sentido de que no se podían hacer modificaciones (Constitución de los Emperadores Valentiniano, Valente y Graciano, del año 371, recogida en el Código justiniano,

VII, XLIV, 2 pr.), añadiéndose en una Constitución de los mismos príncipes, del año 374 (Cód. VII, XLIV, 3 pr.)

Si se condenaba la misma no era necesariamente pecuniaria se podía condenar a la entrega de la cosa adeudada. El condenado también pagaba las costas del proceso. (Epítome de una Constitución griega de Zenón, del año 487, tomado de las “Basilicas” e incluido en las ediciones modernas del Cód. de Justiniano (VII, XLI, 5 pr.).

Efectos de la Sentencia:

- a) La sentencia queda firme cuando no ha sido recurrida por decisión de la parte que tenía derecho a hacerlo y no lo hizo por voluntad propia o porque se venció el plazo; también puede ocurrir cuando se interpuso el recurso de apelación y éste se agotó en todas sus etapas.
- b) Ejecución de la sentencia por medio de la *actio iudicati*.
- c) Habiendo sentencia firme el asunto no puede volver a plantearse judicialmente.

Recursos

No solo estaba el recurso de apelación había otros recursos que se podían clasificar en ordinarios y extraordinarios, ello dependía de la posibilidad de interponerlo como regla o como excepción. Entre los ordinarios estaba la *appellatio* y la *consultatio* o consulta, y entre los extraordinarios la *supplicatio* o súplica y la *in integrum restitutio*.

El recurso de apelación era el medio utilizado por las partes para impugnar la sentencia porque no estaban de acuerdo con el fallo en relación a sus pretensiones, de éste modo buscaban desvirtuarlo. El recurso se presentaba ante un juez superior al que había dictado la sentencia de primera instancia.

Si bien se mantiene el remedio excepcional de la *in integrum restitutio* para los casos en que estaba autorizada ya en el derecho clásico –*ob errorem, ob dolum, ob metus, ob minoraetatem*, etc.- ha desaparecido, en cambio, la *revocatio induplum*, mediante la cual podía llegarse a la declaración de nulidad de la sentencia, la que, sin embargo, puede plantearse oponiendo, contra la *actio indicati*, la *infinitatio* o negativa a acatarla, aunque sin el riesgo de la condena al duplo en caso de ser vencido.

La *appellatio* fue la regla durante la etapa del procedimiento extraordinario, mientras que en tiempos del procedimiento formulario excepcionalmente procedía en contra de lo dispuesto por el juez privado.

El recurso de apelación sólo se interpone contra sentencias definitivas no interlocutorias y como ya se dijo cuando el fallo es dictado en rebeldía de una de las partes.

Se deducía ante el *iudex* que había dictado la sentencia.

A partir de allí podía declararla admisible y le daba curso ante el superior, pero podía ocurrir que la declare inadmisibile, en ese caso, el apelante perjudicado podía recurrir en queja ante el superior jerárquico, quien puede imponer una pena pecuniaria al juez que la denegó, para el caso de que fuera o no procedente la apelación.

Recién en esa instancia el recurso era resuelto por el órgano judicial jerárquicamente superior al que pronunció la sentencia, luego llegaba al emperador.

Como la sentencia era leída y las partes tomaban conocimiento de la misma en ese momento podían hacer la apelación verbalmente, también lo podían hacer con posterioridad, pero por escrito sometidos a plazo el Código y el Digesto era de dos o tres días útiles y las Novelas elevaron a diez días continuos.

Un vez que se interponía la apelación se suspendía la ejecución de la sentencia (Dig.LIX, VII, 1pr.) hasta que se pronuncie un juez superior Justiniano redujo el número de las apelaciones a dos (Código, VII, LXX, 1), pues anteriormente podían deducirse tantas como grados existieran en la escala jerárquica de los órganos judiciales.

El apelante debía tener razón para recurrir, caso contrario se lo tenía por temerario Constantino (Cód. Teodosiano, I, V, 3) dispuso severas penas –destierro por dos años, confiscación de la mitad del patrimonio, condena a dos años de trabajos forzados- *in metallum* – del apelante pobre- contra los litigantes temerarios, luego fueron mitigadas por Justiniano, volviendo al régimen de un rescripto de Diocleciano, que era menos severo en las sanciones (Cód. VII, LXII, 6, 4).

El que perdía la apelación debía, además de lo dispuesto en la condena pagar el *quadruplum* del valor de las costas del proceso correspondientes a la segunda instancia (Constitución de Diocleciano, en Cód., VII, LXII, 6, 4).

Sin embargo además de otros remedios, entre ellos la *supplicatio* o súplica, que tramitaba excepcionalmente a diferencia de la apelación que era de carácter general, ante el emperador, pero agotada ésta vía no podía recurrirse a la apelación.

En lo que respecta al rescripto se hacía primero la *consultatio*, por la cual se remitía lo actuado judicialmente ante un tribunal imperial o al Emperador, se agregaban la *relatio* y los *libellirefutatorii* de los litigantes, que el emperador resolvieran mediante un rescripto.

Vías de Ejecución de la Sentencia

Una vez que la condena quedaba firme, el condenado debía cumplirla de manera voluntaria si no lo hacía se lo hacía cumplir compulsivamente. Ello se hacía por medio de la *actio iudicati*, en un término no mayor de dos meses o de cuatro en el período Justiniano. Según Constituciones recogidas en el Código (VII, LIV, 2 y 3) de los años 529 y 531, si el deudor reconocía la deuda (*confessus*) procedía en contra de él la ejecución.

El Objeto de la Ejecución

Por lo general es la prestación a que el demandado fue condenado en la sentencia, puede consistir en un *facere* pero en este último caso,

si el condenado no lo hace, va a ser condenado a pagar su equivalente en dinero de acuerdo a las pretensiones del actor.

La ejecución va sufriendo transformaciones a medida que pasa el tiempo y que el derecho va evolucionando, al principio se ejecutaba a la persona del deudor insolvente a través de la *manus iniectio*; también se hacía la *pignoris capio* en los casos que la ley y la costumbre autorizaba, luego con la sanción de la *Lex Poetelia Papiria* se prohibieron las ejecuciones mencionadas y las mismas ya prosperaban sobre el patrimonio del deudor insolvente, no solo por el procedimiento de la *bonorum venditio* sino también otros como la *distractio bonorum*, la *bonorum cessio* y la *bonorum sectio*.

No existía la ejecución privada del acreedor sobre el cuerpo (pérdida de la libertad ambulatoria) se autorizaba a llevarlo a cárcel pública, desde los Emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio, o decretando su sumisión a la custodia y vigilancia –*custodia militaris*– de funcionarios a las órdenes del juez.

Si la ejecución era de un solo acreedor se distinguía:

- a) Si la condena era sobre una *certa res* (cosa determinada) se ejecuta *manu militari* por funcionarios dependientes del magistrado que la pronunció, quienes la entregan al ejecutante pero no siempre estaba el objeto, de modo que si la cosa se perdía por destrucción se debía entregar una suma por un monto equivalente al valor que tenía, teniéndose por cierta la palabra del actor bajo juramento.
- b) La condena también podía versar sobre el pago de una suma dineraria, si no la pagaba voluntariamente el condenado se tomaban bienes de su patrimonio como forma de garantizar el pago o posterior ejecución de los mismos para cobrarse de la venta lo adeudado, ésta clase de ejecución (tomar bienes del patrimonio) estaba a cargo de los oficiales auxiliares del magistrado-juez –*apparitores*– quienes tomarán en primer lugar, los muebles, como el dinero que el deudor tuviere en su poder o depositado en el establecimiento de un banque-

ro, luego los inmuebles o cualesquiera otros valores, que el ejecutado puede rescatar dentro de un plazo de dos meses mediante el pago de la condena y que, en su defecto, serán vendidos en pública subasta por los mismos *apparitores*, que pagarán con su precio al acreedor, entregando el remanente, si lo hubiere, al deudor.

Cuando se realizaba la subasta podía ocurrir que hubiera interesados en comprar o no, o no alcanzare para cubrir el monto de la deuda, en los dos últimos casos el acreedor se adjudicaba la cosa, también podía pedir la *impretratio dominii* (Cód. VIII, XXXIV –de la impetración del derecho de dominio), ésta última se hacía por una *transactio* y en caso de que se lleve a cabo no podía accionar judicialmente en contra del deudor.

Si los que accionaban para la ejecución eran varios acreedores se recurría a la *bonorum venditio* del derecho clásico, aunque con modalidades propias y en combinación con la *distractio bonorum*,

Los acreedores obtenían la posesión de los bienes del deudor – *missio in possessionem rei servandae causae*– se designaba para la administración patrimonial un *curator bonorum*.

Había un plazo de dos años para que se presenten aquellos acreedores que no lo habían hecho inicialmente; el plazo se extendía a cuatro años cuando vivían fuera del lugar de radicación del concurso.

Luego se realizaba la venta de los bienes en subasta pública pero no en bloque sino individualmente, lo hacía el *curator*, se parecía a la *distractio bonorum*.

Un vez que se realizaba la venta los acreedores concurrían a prorrata, a veces ocurría que no alcanzaba para pagarles a todos por eso se pagaba siguiendo un orden de preferencia.

Aparecen con la ejecución colectiva en el derecho justiniano, las dos instituciones que siguen:

- a) El convenio entre los acreedores, adoptado por la mayoría de ellos, pero ahora obligatorio para todos, de aceptar una reducción proporcional en el importe de sus créditos, a fin

de facilitar su pago por el deudor (Ulpiano, en Digesto. II, XIV, 10 pr., interp.) que parece haber terminado su origen en el *pactum utminus solvatur* del derecho clásico;

- b) El *moratorium*, convenio entre los acreedores y el deudor en virtud del cual aquellos le conceden un plazo para el pago de sus deudas, beneficio que, según se adelantó, pudo también ser directamente solicitado por el deudor del Emperador (Constitución De Justiniano, del año 531, incluida en el Cód. VII, LXXI, 8, donde se alude a un plazo de cinco años).

Clases de representaciones en el proceso judicial

En tiempos de las legis acciones la regla fue que las partes debían actuar personalmente y no otros en nombre de ellos, hubo excepciones, como los casos del *agere pro populo*, *pro libertate*, *pro tutela* y *ex lege Hostilia*.

En la época del proceso formulario, en la época clásica, se admitieron, aparte de los representantes legales o necesarios, como el tutor o el *curator* de los afectados por una incapacidad de ejercicio o como los actores y los *syndici* de los *municipiae* y de las *universitates* en general, dos tipos de representantes procesales de carácter voluntario, que fueron el *cognitor* y el *procurator*.

El *Cognitor*

Era el representante designado por el litigante interesado con palabras solemnes y en presencia del adversario. Cuando la *actio* ejercida por éste se extinguía como si lo hubiese hecho en persona su representado, la intervención del *cognitor* hace que el representado no pueda volver a intentar en el futuro la *actio* nuevamente.

El *procurador*

Para su designación no se requerían los modos de designación del *cognitor*. Con su intervención no ocurría lo mismo que en el caso

anterior porque al ser designado extrajudicialmente y sin que sea necesaria la presencia del demandado, éste podía cuestionar sobre la existencia de su representación real, de modo que si no tenía plenas facultades para representar el actor podía ejercer nuevamente la *actio* en contra del demandado, para evitar esto se ofrecía la *cautio* de rato. Se presume que existió ésta figura porque se quería evitar que una persona quedara indefensa por una cuestión técnica de que el nombramiento debía ser de un modo solemne, así se evitaba a la vez que en el peor de los casos un sujeto fuera condenado y ejecutado en su patrimonio.

Al principio se hizo en beneficio del demandado; luego en beneficio del actor, para evitar que éste salga perjudicado por una prescripción de la acción.

Efectos de la actuación por medio de representantes

- a) Intervención del representante y representado en la fórmula: La transposición de sujetos

Si el que litigaba por medio de un representante era el actor, ya se tratara de una *actio in rem*, ya de una *in personam*, en la fórmula expedida por el pretor se daba una transposición de sujetos, ya que en su *intentio* figuraba el nombre del representado, mientras que en la *condemnatio* aparecía el del representante si el derecho del representado resultaba acreditado.

Si era el demandado quien se hacía representar en el juicio por un tercero, en la fórmula respectiva sólo había transposición de sujetos cuando ella correspondía a una *actio in personam* porque, como oportunamente se dijo, en las correspondientes a las *actiones in rem* no figuraba el nombre del demandado en la *intentio*.

- b) Presentaciones de cauciones o garantías

Cuando el actor estaba representado por un:

- 1) Cognitor: no prestaba caución.
- 2) Procurador: éste otorgaba la *cautio* de rato o *cautioratam*

rem dominum habiturum: Asumía el compromiso de que su representado iba a ratificar lo actuado por él.

Cuando el demandado estaba representado por un:

- 1) Cognitor: éste otorgaba la *Cautio iudicatum solvi*.
- 2) Procurador: éste otorgaba la *Cautio iudicatum solvi*: se asume con el compromiso de que se va a cumplir con lo dispuesto por la sentencia.

Otros Intervinientes en el Proceso

- 1) Los *iurisconsultus* o *iuris-prudentes*: Evolución:
 - a) Eran los que realizaban los dictámenes o responsa, respuestas de aquellas cuestiones que las partes les habían solicitado se expidiesen, redactaban pliegos dirigidos al juez, también podían hacerlo de manera verbal a la parte que así lo requería. Su actuación se daba antes del proceso o durante éste pero sin que sea requerida su presencia.
 - b) En un momento dado, solo algunos juristas tuvieron el respaldo del príncipe para emitir dictámenes que influirían en la decisión del *iudex* –*ex auctoritate principis*.
 - c) En tiempos de las *legis actionis* dirigían y guiaban a las partes en el proceso; durante el procedimiento formulario los asesoraban en como redactar la fórmula en el Edicto.
- 2) Los *oratores* y los *patroni*, quienes hablaban en los debates, en representación de las partes.
 - a) El *orator* era aquel que sabía desplegar muy bien el arte de la elocuencia, trataba de convencer al *iudex* haciendo un análisis de la prueba de que su representado tenía la razón más allá de que fuera cierto o no, no tenía ninguna clase de preparación jurídica. El más destacado fue Cicerón.

- b) El *patronus*: Se tenía en cuenta su elevado rango o posición social, su rol era similar al del orador. Se trataba de una persona socialmente influyente.
- 3) Los *advocati*: Contaban con conocimientos en derecho con el fin de asesorar a las partes. Con la desaparición del *ius publice respondendi ex auctoritate principis* también desaparece la distinción entre *advocatus* y *iurisconsultus* (en tiempos del Bajo Imperio).
- 4) Al principio eran actividades gratuitas, no podían tener el rango de locación de servicios¹⁸.
- 5) Con el paso del tiempo, los asesorados deciden contribuir a colaborar con un pago, de allí surge la denominación de *honorarium* a posteriori fue prohibido por ley *Cincia donis et muneribus* (s.III a.c.) hasta que el Emperador Claudio estableció la posibilidad de un pago que no excediera de los diez mil sesteracios.

Nerón consideró su pago como una verdadera *obligatio* del litigante, cuyo cumplimiento puede perseguir el abogado mediante la *cognitioextra ordinem*. Pero quedaron prohibidos el pacto de *quota litis* (Ulpiano, Dig., L, XIII, 1, 12), el *palmarium* y el pacto de *redemptio litis* (Ulpiano, Dig., XVII, I, 6, 7), consistentes el primero en el convenio por el cual se acordaba pagar al abogado un porcentaje de lo que se cobrara como resultado del juicio, el segundo en aquel por el cual se pactaba que sólo se cobrarían honorarios en caso de obtener una sentencia favorable, y el último, en convenir que el abogado sustituyera al cliente en el resultado del pleito, de modo tal que si éste se ganaba, fuera aquél quien se beneficiaba, y si se perdía, cargara con la condena.

18 D. XIII, 1

Sobre la Prueba Testimonial en Roma

A) La Prueba como Actividad Procesal

La prueba se constituye como una actividad meramente procesal que se lleva a cabo a través de los medios que preestablece la ley cuyas modalidades pueden ir variando, se puede tratar de: documentos (instrumentos públicos y privados), testigos, juramento (confesional), etc.

De éste modo la reunión de ellos en un proceso judicial, si se toma como lo entiende el derecho procesal moderno se constituirá como una reconstrucción de la verdad histórica lo más fiel posible a ella; con la finalidad a la vez de convencer a quienes tienen la tarea de juzgar de quien tiene la razón quién pudo probar lo que alega y quién no.

En lo que respecta a la prueba testimonial hay criterios preestablecidos y parecería que con un margen de amplitud: Debe darse crédito al testimonio de un esclavo cuando no hay otra prueba para averiguar la verdad. (Mod. (8 reg.)¹⁹.

B) Valoración de la prueba en general

En aquellos tiempos en los que el derecho se encontraba bajo la influencia de lo religioso (fas), en los que, la norma de los dioses era la ley de los hombres como un todo inescindible la exigencia de la prueba aparece bajo el cumplimiento de rigurosas formalidades, condición sine qua non para el nacimiento de los actos a la vida jurídica.

En tiempos del procedimiento formulario continúa rigiendo, respecto a su producción, el principio de que ella incumbe a quien afirma y no al que niega (*incumbit probatio ei qui dicir, nonqui negat*) (Paul.69 ed.)²⁰. No obstante si bien el demandado en éste sentido adquiriría una conducta pasiva ya que solo debía rebatir las pruebas de cargo que el demandante presentaba, asumía un rol más activo cuando oponía excepciones ya que lo que alegaba debía probarlo²¹. (3)

¹⁹ D. XXII,4, V,7

²⁰ D. XXII, 3,2

²¹ D. XXII,3 Y D. XLIV,1

El mismo Emperador Adriano decía en un rescripto a Junio Rufino, procónsul de Macedonia que “él daba fe a los testigos y no a los testimonios escritos, que no se admiten en mi jurisdicción (pues yo suelo interrogar personalmente a los testigos), remití (el asunto) al Gobernador de la provincia, para que éste indagara la veracidad de los testigos, y si, (el acusador) no probaba su acusación; fuera desterrado”.

En lo que respecta al procedimiento extra *ordinem* en la valoración de la prueba se va dando de manera paulatina una nueva forma de operar que restringen la amplia libertad de que disfrutaba el *iudex* en el procedimiento formulario, pues se atribuye legalmente mayor valor a unos medios de prueba que a otros, concurriendo los cuales el juez deberá dar por acreditados ciertos hechos, cualquiera que sea su íntima convicción formada sobre la base de otros elementos o pruebas a que la ley concede menor valor.

El criterio que domina esta nueva posición del derecho romano-bizantino en punto a la apreciación de la prueba se traduce, pues, en general, en un marcado disfavor contra la testimonial, que contrasta con la preferencia por la escrita, de éste modo se cita en el Digesto que resolvió el senado que el registro y los documentos públicos valieran más que los testigos (Marcell. 3 dig.).²²

Los Testigos son apreciados no por el número sino por el valor de sus testimonios²³

C) ¿Quiénes eran requeridos como testigos?

En la diversidad de actos en los que será necesario contar con testigos, éstos deberán gozar por parte de quien los invoque de plena confianza, con respecto a esto último el Digesto establece que si todos los testigos son de la misma honradez y reputación, y la clase del negocio y la opinión del juez concurren con ellos, deben seguirse todos los testimonios; pero si alguno de ellos hubieran declarado algo distinto, aunque no sean en igual número, debe darse crédito

22 D.XXII, 3,10

23 D.XXII,5

con lo que es congruente con la naturaleza del negocio o no presente sospecha de enemistad o favor, y el juez confirmará su opinión con los argumentos y testimonios, y lo que pudiera encontrar como más adecuado al asunto y más próximo a la verdad. No debe, pues, atenderse a la mayoría, sino a la exactitud sincera de los testimonios, y a los testimonios que cuentan a su favor con más luz de la verdad. (Arc. Char., De testib.)²⁴. Pueden aducirse testigos en las causas criminales, en los litigios patrimoniales, cuando lo pida el asunto, en general aquellas personas a las que no se prohíbe dar testimonio ni están excusadas de ello por ningún juez...las constituciones imperiales limitan el número de testigos, en el sentido de que no resulte sobreabundante en el número y en los dichos que puedan alegar de modo que los jueces puedan determinarlo y permitan que se cite el número de testigos que ellos juzguen necesario, tampoco permitiendo que con éstos accionares se desvirtúe la naturaleza del instituto.

D) ¿Cuáles serán las cualidades que deben tener los testigos?

Independientemente de las prohibiciones legales, que serán tratadas posteriormente, quiénes están habilitados a prestar testimonio deberán reunir cualidades especiales que harán creíbles de manera inequívoca sus dichos, como lo señala el Digesto en los testigos debe tenerse en cuenta la dignidad, la veracidad, las buenas costumbres y la gravedad, todos éstos aspectos hacen a la seguridad del mismo, seguridad que no admite las dudas caso contrario no debe ser tenido en cuenta (Mod. 8 regul.); la declaración dubitativa de un testigo podía responder a la intencionalidad de perjudicar a una de las partes: “Los testigos que declararon en falso o en contradicción con ellos mismos o que traicionan a las dos partes deben ser castigados por los jueces como corresponde”. (Paul.5 sent.)²⁵.

24 D. XXII,4, V,18

25 D. XXII,4, V,16

Será necesario el análisis de la persona del testigo, para tener certeza de la eventual veracidad que pudiera tener, para ello debe tenerse en cuenta las cualidades de cada uno;

- si es decurión o plebeyo;
- si es persona de vida honesta e intachable
- o bien de mala fama e indigno;
- si es rico o pobre que pueda dejarse llevar fácilmente por el lucro;
- si está enemistado con aquél contra quien depone en testimonio, o amigo del que favorece con el mismo.
- Si no hay sospecha en su testimonio, por la persona que lo da (porque es honorable) o por la causa (porque no lo da por lucro, favor o enemistad), el testigo debe ser admitido.

1) Posible Determinación de la Veracidad del Testimonio

Ya en tiempos del Emperador Adriano, a través de un rescripto se dispuso que quien se encarga del juzgamiento es el idóneo para determinar qué testigo va a obrar con veracidad pareciera que fuera así solo por la función de juez, ya que es el que los escucha, los interroga y de varias declaraciones colectadas se compararan entre sí para demostrar si son similares en su estructura, contenidos, espontaneidad, ya que el testigo debe demostrar que lo que dice es real y lo expresa con sinceridad, de modo que el conjunto de éstos aspectos lo hacen merecedor de confianza y por lo tanto un testimonio fidedigno. La espontaneidad del discurso es necesaria discernirla, para evitar los artulugios a través de un relato armado.

La veracidad de una declaración o de varias declaraciones al mismo tiempo no implica que deba ser tenido como un medio de prueba contundente e infalible, lo que tampoco lo hace taxativo, pero reduce el margen de probabilidades en las declaraciones mendaces. Por ende, no se puede decir en general cual medio de prueba resulta más contundente para probar la verdad de cómo acaecieron los hechos, ella puede surgir de lo que fuere público o privado, va a depender

de cada situación en particular, a veces como se dijo, de la armonía lógica en las declaraciones de varios testigos y en los interrogatorios, también como se han conducido y si cumplen en general con los requisitos.

Se le da potestad a quién tiene la tarea de juzgar para que determine cuales son los medios de prueba idóneos para determinar la verdad en el caso en particular a tratar²⁶.

Es dable la importancia de los testigos, parecería una preeminencia de éstos sobre las declaraciones que pudieran leerse en el juicio²⁷.

2) Casos en los que existe duda de la veracidad acerca de la declaración²⁸:

- a) Se dispone en la ley Julia sobre la violencia que no se admita en los juicios de ésta ley un testimonio contra el acusado de parte de quien recibió de él o de su padre la libertad,
- b) de los que sean impúberes, del condenado en un juicio público sin haber sido rehabilitado,
- c) del preso en cárcel o en custodia pública,
- d) del que se alquiló para luchar con las fieras,
- e) del juzgado o convicto de haber recibido una cantidad por dar o no dar testimonio;

26 Del mismo príncipe hay un rescripto a Valerio Vero sobre el examen de los testigos, en los siguientes términos: “No puede definirse de forma determinada que pruebas resultan suficientes para probar cada cosa. La verdad, no siempre, pero sí muchas veces puede averiguarse sin constancia pública. Unas veces el número de los testigos, otras veces su dignidad y autoridad, otras su buena fama general pueden confirmar la verdad del caso. Tan solo te puedo decir sumariamente que no se debe dar fe sin más a una sola clase de pruebas recibida, sino que debes estimar según tu criterio qué debes creer o juzgar como insuficientemente probado”.

27 El mismo príncipe decía también lo siguiente en un rescripto a Gabinio Máximo: “Una es la autoridad de los testigos presentes y otra la de los testimonios escritos que suelen leerse en el juicio; piensa, pues, que si quieres retener a los testigos, has de pagarle los gastos”.

28 Ya sea por respeto a ciertas personas, en otros casos por la inseguridad de su juicio, otros por su deshonor e ignominia de su vida no deben ser admitidos a dar testimonio

E) El rol de los testigos en los distintos actos jurídicos

Cuando se realizaba en tiempos de Justiniano la *manumissio in sacrosanctis ecclesiis*, en las Iglesias ante el obispo, la congregación, en la Pascua, luego de la declaración del dueño del esclavo se redactaba un libelo solemne o escritura en la cual los presentes firmaban como testigos²⁹.

Para la celebración de la *manumissioperepistolam* se le daba la libertad al esclavo ausente a través de una misiva o carta³⁰; Justiniano exigió además que cinco testigos firmaran o dieran fe del contenido de la carta³¹.

En la *manumissio interamicos*, en presencia de cinco testigos el *dominus* le anunciaba la libertad al esclavo³².

Sobre la base de la *Lex Aelia Sentia*, se estableció por la Ley *Iunia* que los menores de treinta años manumitidos y convertidos en latinos, en caso de tomar por mujeres a ciudadanas romanas o latinas colonarias o mujeres de su misma condición siempre y cuando ello fuera atestiguado por siete testigos ciudadanos romanos púberes, y que además hayan procreado un hijo.³³

La adquisición de la *manus* sobre la mujer, como una de las formas más antiguas que se conocían, se hacía con el acto solemne que se dividía en tres partes: la *traditio* de la mujer; la *deductio in domu*: el acompañamiento de la mujer por el cortejo que entonaban cánticos religiosos y la acompañaban hasta la puerta de la que iba a ser la casa conyugal; luego como tercer paso la *confarreatio* propiamente dicha, donde se ofrecía la comida del pan de cebada al dios Júpiter y se recitaban fórmulas solemnes; en presencia del *flamen dialis* y diez testigos³⁴.

29 C. Theod.; 4,7,1. C.I, 13,1 y 2

30 D. 61, II, 38

31 C., 7,6,1.

32 G. I nota 15

33 Gaius I, 29.

34 GAIUS I, 112

Por otra parte se conviene la *manus* por la *coemptio*, era una venta ficticia o imaginaria, en presencia de no menos de cinco testigos ciudadanos romanos púberes y un *libripens*³⁵.

La *mancipatio* se hacía en presencia de cinco testigos³⁶

En los comicios cuando se realizaban los testamentos, una de las formas más antiguas de testar que ha conocido el derecho romano, se realizaban en presencia del pueblo tal como si se tratara de una ley rogada, laque debía prestar su consentimiento para el acto de transmisión de la universalidad jurídica, tal como se señala en *Gaius* en el *testamentum Calatiae Comitiae*....o se sabe con certeza si los comicios obraban como testigos o debían dictar una ley..³⁷

En cuanto al *Testamentum in procinctu*...el compañero de armas era un testigo solemne de la declaración del testador³⁸.

Con respecto al *testamentum procinctu*, se llamaba *per aes et libram* porque se realizaba por el ritual del cobre y la balanza (*mancipatio*)³⁹ se detalla el procedimiento: “quién hace el tto., en presencia como en las otras mancipaciones, de cinco testigos ciudadanos romanos púberes y un *libripens*, después de haber escrito las tablas del testamento, mancipa a un tercero- por mera formalidad.- su patrimonio (*familiam suam*) y en tal circunstancias son usadas palabras solemnes⁴⁰: golpeaba con el cobre la balanza y se lo da al testador en lugar del precio. Luego el testador teniendo las tablas del testamento dice así: “*De acuerdo con lo que está escrito en éstas tablas y en ésta cera, yo doy, lego y testo, por lo tanto vosotros quirites, dame testimonio de ellos*”; éste acto se llama *nuncupatio*.⁴¹.

35 GAIUS I- 113

36 GAIUS I- 119

37 según la nota 94 de GAIUS II-102

38 Nota 94, GAIUS II- 102

39 en G. II-104

40 “Yo me encargo por mandato tuyo de custodiar tu familia y tu fortuna, y a fin de que tu puedas en derecho hacer tu testamento de acuerdo con la ley pública, sean por mi compradas, por ésta moneda de cobre” (y algunos agregan) “por ésta balanza de bronce”.

41 en G. II-104. Nuncupare significa designación pública hecha por el testador de acuerdo a lo establecido por las tablas del testamento.

Se estableció que “la manera de formalizar el testamento tuvo cambios con posterioridad a lo que dice Gaius. En primer término fue el pretor quién permitió que se dejara de lado la ceremonia de la *mancipatio*, siempre y cuando que se celebra ante siete testigos y éstos pusieran sus sellos⁴², luego en la época imperial se van introduciendo nuevas reformas hasta llegar al *testamentum tripertitum* de Justiniano, que consistía en un acto uno contextu, o sea no interrumpido y continuo, lo cual aparece como una exigencia del derecho civil, ya que la interrupción de un acto celebrado ante los comicios, anulaba todo lo sucedido hasta entonces.

También el derecho civil tenía la exigencia de los testigos que debían ser siete conforme al número fijado por el pretor. A parte éstos Testigos debían fijar sus sellos (exigencia del pretor) previa *subscriptions* del testador y de los mencionados testigos (exigencia del derecho imperial). Precisamente porque las formalidades emanaban de los tres derechos es que se llamaba a éste testamento *tripertitum*⁴³. A su vez el testamento puede ser escrito, en cuyo caso aparte de las formalidades analizadas era exigencia que para evitar fraudes, el nombre del heredero debía ser escrito de puño y letra por el testador o uno de los testigos⁴⁴, pero podía ser oral (nuncupativo) pronunciado ante siete testigos y haciendo ante ellos la declaración solemne de voluntad⁴⁵. Ésta variedad de las formas de testar en Justiniano, es consecuencia directa del sentido estoico que le da a la etimología de *testamentum* (*testatio mentis* –testimonio de voluntad), la cual difería del sentido quiritario que estaría dado por la declaración solemne ante los comicios, como testes (testigos) con un valor significativo de *lex*.

42 cfme. Insts. II, 10,2

43 cfme. Insts. II, 10,3

44 cfme. Insts. II, 10,4

45 cfme. Insts. II, 10, 14

A) ¿QUIÉNES NO PODÍAN TESTIMONIAR?

A éste respecto se podrían considerar varios casos, en los que no habría un testimonio válido como el de los judíos y herejes contra litigantes cristianos u ortodoxos⁴⁶.

También se puede hacer referencia a la condición social de los testigos⁴⁷, la que reduce la obligación de reforzar sus declaraciones con juramento a los testigos de las clases inferiores⁴⁸, la que permite la aplicación de la tortura a los testigos sospechosos de faltar a la verdad⁴⁹, etc.

Quién se encuentra bajo la *potestas* del *familiae emptor* o del mismo testador no puede servir de testigo, ya que para imitar en un todo al derecho antiguo en las formalidades que se practican para hacer testamento, solo se consideran parte del negocio al testador y al *familiae emptor*, y como antiguamente quién compraba el patrimonio tomaba el lugar de heredero, es por ello que en este acto no se admite al testigo doméstico.

Las reglas generales establecían que no podían ser testigos:

- Ningún testigo puede ser idóneo en su propia causa (Pomp.1 Sabino)⁵⁰.

- las mujeres

- los esclavos

- El condenado por exacciones ilícitas no puede intervenir en un testamento ni dar testimonio⁵¹.

- los impúberes

- No debe citarse temerariamente a testigos que deben recorrer un gran camino para venir a juicio, y mucho menos hay que apartar a los militares de sus banderas y encargos para dar testimonio, y así se dice en un rescripto del Emperador Adriano,

46 Const. De Justiniano, en Cód. I, V, 21 pr.

47 Cód, IV, XX, 9; Novelas, 90, 1

48 Const. De Constantino en Cód, IV, XX, 9

49 Novelas, 90, 1

50 D. XXII,4, V,10

51 D. XXII,4, V,13

- los furiosii
- los mudos
 - los sordo
 - El acusador no debe llamar como testigo al reo de un juicio público ni al menor de veinticinco años. (Venul. 2 iu. Publ.)⁵²
 - -los pródigos declarados tales
 - -los declarados indignos de testar por la ley (*intestabiles*)
 - - los herederos ni los que están bajo la *potestas* del testador o del heredero, pero el enlace entre los testigos no perjudica.
 - No es testigo idóneo el padre respecto al hijo ni el hijo respecto al padre (Paul. 1 Sap.)⁵³

En tiempos de Justiniano será regla de carácter obligatorio que el heredero y quienes estén bajo su *potestas* sean testigos⁵⁴.

La estricta observancia de estas formalidades en la celebración de los testamentos, ha sido dispensada a los militares por las constituciones del príncipe a causa de su gran inexperiencia. Así cuando no hayan presentado el número legítimo de testigos, ni hayan vendido la *familia*, ni hayan *nuncupado* el testamento, éste no por ello deja de ser válido”; de acuerdo a lo establecido en la nota nº 100: los militares tienen otras ventajas: a) pueden instituir como herederos a aquellos que no tienen la *testamentifactio* pasiva⁵⁵.

Si el testamento está firmado por siete testigos, el pretor le ofrece a los herederos inscriptos, conforme a las tablas del testamento, la *possessio* de los bienes (*bonorum possessio*)⁵⁶.... El pretor considera que con los siete testigos en principio no se dudaría de la existencia de un

52 D. XXII,4, V,20

53 D. XXII,4, V,9

54 Nota 99 v. Insts. II,10,10

55 G., II, 109 y nota nº100

56 G. II, 119; de acuerdo a lo establecido en la nota 105: se trata de un caso de b. Possessio secundum tabulas

testamento, aún cuando falten las otras formalidades y en consecuencia a los allí inscriptos los va a nombrar *possessores bonorum*.

Se dispone en la Ley Julia de los juicios públicos que no se convoque a nadie contra su voluntad para que dé testimonio contra su suegro o yerno, padrastro o hijastro, primo o prima segundos, o el hijo de éstos, o los de grado más próximo; tampoco al liberto del acusado, o de sus hijos o ascendientes, del marido o la mujer, ni al del patrono o de la patrona, de suerte que no se obligue a dar testimonio a los patronos o patronas contra sus libertos ni a los libertos contra el patrono (Paul. 2 ad leg. Iul. Et Pap.)⁵⁷.

En las Leyes en las que se exceptúa que no se obligue a dar testimonio contra su voluntad al yerno o suegro, se admite que se comprende en el nombre de yerno también al prometido de la hija, y en el de suegro al padre de la prometida. (Gai. 4 ad Leg. Iul. et. Pap.)⁵⁸

No parecen idóneos los testigos a los que (el interesado) puede ordenar que lo sean. (Lic. Ruf. 2 reg.)⁵⁹

No deben ser obligados a dar testimonio contra su voluntad los viejos, los enfermos, los militares, los magistrados que están ausentes en viaje oficial, o los que no pueden acudir (Scaev. 4 reg.)⁶⁰.

Para dejar constancia de un acto se entiende como testigo incluso el que no fue rogado a ello. (Pomp. 33 Sabino)⁶¹

Cuando no se señala el número de testigos, bastan incluso dos, pues bastan dos para decir que son varios. (Ulp. 37 ed.)⁶²

Sé que se ha discutido si pueden deponer testimonio en los juicios públicos los condenados por acusación calumniosa, pero ni se prohíbe en la ley Remnia, ni impidieron que tales personas den testimonios de leyes julias sobre la violencia, exacciones ilícitas y peculado. Sin embargo, lo que olvidaron las leyes no debe olvidarlo la atención

57 D. XXII,4, V,4

58 D. XXII,4, V,5

59 D. XXII,4, V,6

60 D. XXII,4, V,8

61 D. XXII,4, V,11

62 D. XXII,4, V,12

de los jueces, a cuyo ministerio corresponde valorar la veracidad del testimonio que puede una persona proclamar con la frente alta. (Pap. 1 de adult.)⁶³

Se ha establecido que el condenado por adulterio no puede ser testigo de un testamento, pesa en éste caso la prohibición, por lo que ésta clase de declaraciones no gozan de validez, ni las consecuencias que ello acarrea⁶⁴.

La casuística ha llevado a contemplar el caso de las personas que no tienen el sexo definido; “El que pueda intervenir en un testamento el hermafrodita depende del sexo que predomine en él. (Paul. 3 sent.)”⁶⁵.

El padre y el hijo que está bajo su potestad, así como dos hermanos que están bajo la misma potestad, pueden ser castigados ambos en el mismo testamento o en el mismo negocio, porque nada perjudican que intervenga en un negocio ajeno varios testigos de la misma casa. 8Ulp.,reg.⁶⁶

De la Ley Julia sobre los adulterios prohíba a la que la mujer condenada pueda testimoniar se deduce que las mujeres tienen el derecho de deponer testimonio en su juicio. (Paul.,2 de adult.)⁶⁷

No son testigos contra su voluntad los publicanos, ni el que se hubiera ausentado (por causa justificada y) por no rehuir el testimonio, ni el que hubiera hecho la contrata de suministrar al ejército. Tampoco se pude citar como testigos a los pupilos. (Ulp. 8 de off.proc.)⁶⁸

Se estableció: que “el condenado por libelos infamantes se hace incapaz de testimoniar. También decretó el senado que el pretor debe dar testimonio en el juicio a causa de adulterio. Pero en una circunstancia en la que hay necesidad de admitir como testigo a un gladiador

63 D. XXII,4, V,13

64 Por ejemplo no se puede dar la posesión de los bienes hereditarios. Ver en D. XXII,4, V,14

65 D. XXII,4, V,15

66 D. XXII,4, V,17

67 D. XXII,4, V,18

68 D.XXII,4, V,19

o persona semejante, no debe darse crédito a su testimonio si no es mediante tormento”.⁶⁹

No puede presentarse como testigo quién con anterioridad ya dio testimonio contra el mismo acusado.

No existe idoneidad para que declaren los testigos que tuvieran un vínculo estrecho con éstas de modo que se pusiera en duda la veracidad de los dichos “No se admite que sean interrogados aquellos testigos que el acusador hubiera traído de su propia casa. (Paul. 5 sent.)⁷⁰.

En los mandatos (imperiales) se pide que cuiden los gobernadores de las provincias de que los patronos no den testimonio en la causa a la que prestaron su patrocinio; lo que debe observarse en los agentes judiciales de ejecución. (Arc. Char., de testib.)⁷¹.

FRANJA
MORADA

69 D. XXII,4, V,21

70 D. XXII,4, V,24

71 D. XXII,4, V,25

Agradecimientos

A mis queridos Maestros del Derecho Romano, con el cariño y respeto de siempre:

Héctor Eduardo Lázzaro, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

Doctor Luis Rodríguez Ennes, Catedrático de la Universidad de Vigo, España.

FRANJA
MORADA